

Cámara del Trabajo de Córdoba, sala 2

Restivo, Sergio G. c. Esso S. A. • 02/08/1991

Córdoba, agosto 2 de 1991.

¿Es procedente la demanda en la que se persigue el cobro de diferencias de comisiones por ventas directas e indirectas: diferencias de comisiones por cobranzas y las diferencias que surjan de las anteriores y que incidan sobre sueldo anual complementario, vacaciones, feriados nacionales, indemnización sustitutiva del preaviso e indemnización por clientela? En su caso, ¿qué resolución debe dictarse en definitiva?

El doctor Podestá dijo:

Habiendo quedado trabada la relación procesal en los términos transcritos, pasaremos al análisis y valoración de la prueba rendida en autos, que lo haremos de acuerdo a los principios que rigen la sana crítica racional para que de ello emane la resolución a dictarse. En la oportunidad de la audiencia de la vista de la causa se recepcionaron las confesionales del actor y del representante de la accionada, Armando A. Decanio, y la testimonial de Andrés E. Ramón Llabot, Norberto E.

Debarre y Oscar F. Floreta. Sergio G. Restivo al absolver posiciones acepta como cierto que fue representante de zona de la firma Esso SAPA (posición 1ª); acepta que entre sus obligaciones laborales estaba a su cargo verificar las existencias, cantidad y calidad de los productos vendidos por las estaciones de servicio o agentes Esso (posición 2ª), agregando que además de las verificaciones tenía que vender lubricantes, grasas, baterías y accesorios, como por ejemplo baterías, neumáticos, correas, filtros, lámparas, etc; reconoce que también era su función controlar las condiciones de presentación de los locales e instalaciones de las estaciones de servicio Esso (posición tercera); contesta afirmativamente cuando se le interroga sobre si también debía controlar y vigilar la calidad de prestaciones de servicios, tales como engrase, lavado, funcionamiento de surtidores, etc. (posición cuarta), aclarando que además verificaba que el personal tuviera correctamente los uniformes de la compañía; negó que su principal obligación era verificar y exigir el cumplimiento de las disposiciones que Esso SAPA, convenía con las estaciones de servicio autorizadas (posición 5ª), acotando que su función principal era la de vender; acepta que las estaciones de servicio o concesionarios de Esso, sólo pueden adquirir y vender productos comercializados y/o producidos por dicha firma (posición 6ª); reconoce como cierto que las estaciones de servicio o concesionarios de Esso compran el combustible por pedidos que hacían en forma directa a la Empresa (posición 7ª); aclarando que entre los objetivos la empresa incluía la venta de gas-oil a crédito a los distintos operadores y les daban el material al respecto; negó que los pagos por las compras de combustibles se efectuaban a los

transportistas que descargaban el combustible solicitado (posición 8ª), pero aclaró que los que vendía el absolvente a crédito lo cobraba él; los otros los pagaba al transportista y que a él le liquidaban sobre todo lo vendido en su zona, aunque considera que le liquidaban las comisiones por cobranzas, pero mal, como figuran en los recibos; acepta que mientras se desempeñó como representante de Zona de Esso SAPA, nunca formuló reclamo alguno para que se le pagaran diferencias de sueldos y/o comisiones pactadas (posición 9ª); dijo no saber que el sueldo que como representante de zona percibió durante el desempeño de dicho cargo para Esso, era superior al establecido en el Convenio Escalafón de la Federación Argentina Sindical de Petroleros; reconoció que Esso SAPA, le ayudó a adquirir un vehículo Renault 12, otorgándole a tal fin un préstamo que devolvió en 60 cuotas mensuales; aceptó que la devolución del préstamo para adquirir el vehículo se realizó en sesenta cuotas; negando que sólo pagaba el quince por ciento de cada cuota, porque el ochenta y cinco por ciento de la cuota lo absorbía Esso, en razón de un reconocimiento por el desgaste del automóvil; pero aclaró que se hacía un reconocimiento por kilómetro recorrido; contestó afirmativamente cuando se le preguntó que el porcentaje a su cargo en la financiación del vehículo antes aludida era devuelto a Esso, sin interés ni actualización alguna. El representante legal de la demanda al absolver posiciones, negó que Sergio G. Restivo vendía productos de Esso, circunstancia por la cual no se formuló la segunda parte de esa misma pregunta, ni la posición segunda. Negó que el actor realizara cobranzas a los concesionarios, pero aclaró que la función de cobranza no era una actividad

primaria o principal, y que es probable que esporádicamente la haya hecho. Se renunció la posición cuarta, y dijo no saber si es auténtica la tarjeta de presentación que se le exhibió y que se encuentra adicionada al pliego de posiciones, acotando que la tarjeta tiene la forma con lo que hacía Esso SAPA. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si Restivo reemplazó en la zona a Daniel H. Dellepiane, agregando que no sabe si lo es como lo informa el perito contador; no se formularon las posiciones séptima y octava, por estar referidas a la pericia contable que dijo desconocer. Reconoció como cierto que el mayor volumen de ventas de la zona de Restivo lo constituía la venta de "nafta súper o común", en la proporción de cerca de un noventa por ciento, agregando que la venta o despacho de la compañía en esa zona, es mayoritariamente combustible; negó que el suplemento de comisiones por ventas que se le otorgaba a Restivo del uno por diez mil, significaba igualmente que los primeros diez mil australes, no devengaban "comisión" y recién a partir de diez mil un australes devengarán los primeros centavos, aclarando que no tiene conocimiento de la mecánica que se hace por computación es decir automatizado; negó que fuera cierto que el suplemento por cobranzas que se le otorgaba a Restivo del uno por cien mil, significaba igualmente que los primeros cien mil australes no devengaban tampoco "comisión" y recién a partir de esa cifra comenzaban los primeros centavos, remitiéndose a la aclaración realizada en la pregunta anterior. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si el sueldo fijo mensual era la forma exclusiva o principal de abonar a Restivo, aunque aclaró que la remuneración del actor por sueldo, suplemento por comisión,

suplemento por cobranza, transferencia de una zona a otra, y que el sueldo no era fijo porque la Compañía lo actualizaba constantemente. Negó que el actor desempeñara idénticas o similares tareas que los señores Andrés Llabot, Joaquín Fernández Riga, Hugo C. Ellif, Norberto E. Debarre y Carlos A. Trensál, por supuesto en distintas zonas de actuación. Se renunció a la posición décima cuarta; negó que el actor rindiera cuenta de las ventas y cobranzas en forma periódica y de acuerdo a las directivas de la empresa; negó que el actor se lo incluía en un libro especial del art. 10 de la ley 14.546 de hojas móviles, como viajante de comercio; negó que el actor se le otorgara la indemnización por clientela al ser despedido como manda el Estatuto Especial del Viajante, acotando que cuando se lo desvinculó, se le pagó una indemnización, aunque no de esa ley. Se renunció a la posición décima octava. Veamos ahora los dichos de los testigos, así Andrés E. R. Llabot, comerciante gastronómico, dice conocer al actor y que conocía a la demandada cuando trabajó para la empresa, donde ingresó en 1974 y hasta el 31 de enero de 1973, primero como oficinista, luego como representante de zona-vendedor, hasta su renuncia. Que le hizo juicio, con el patrocinio del doctor Villagra a la empresa, que terminó favorable para el dicente. Que no conoció a Dellepiane, y sí a Norberto Debarre, quien era compañero de tareas. Que la principal tarea del representante de zona, tenían la responsabilidad de una zona geográficamente bien delimitada, era mantener la atención correcta de la clientela y la venta de los productos distribuidos o patrocinados por la empresa, porque no los fabricaba; aperturas de nuevas cuentas corrientes, cobranzas, complementados

con objetivos para vender, y los que vendían bien eran considerados buenos y eficaces vendedores. Se recorría la zona periódicamente, aunque no eran visitas organizadas, pero debían visitar una vez al mes, por lo menos, y si el cliente era de envergadura una vez cada 15 días. Vendían la línea de lubricantes para automóviles y máquinas; combustibles, y si bien el agenciero o concesionario de estación de servicio hacía el pedido directo, tenían que controlar la venta, sobre todo a los principales compradores (empresas de ómnibus o estaciones de servicios grandes). Además vendían cubiertas Good Year, baterías Champion y todos los repuestos o accesorios de automotores en general, como correas, tapas de tanque de nafta, etc., e insecticidas y artículos de limpieza, asfalto para empresas constructoras, productos para el agro. Le liquidaban y firmaban un papel que venía de casa central, con una lista especial, en que constaba la zona y los artículos vendidos, venía una planilla con las ventas y otra con la cobranza, y recuerda que le pagaban un uno por diez mil en las ventas y un uno por cien mil por las cobranzas, y que puede decir que la suma de las dos comisiones eran ínfimas, sobre todo por las cobranzas. Reconoce que nunca sacó cuentas, pero a su criterio eso alcanzaba para comprar dos paquetes de cigarrillos. Interrogado por la parte demandada, expresa que ese sistema y lo expresado es de cuando el testigo trabajaba, y que no se sabe lo que pasó después, aunque conoce a gente que siguió trabajando, no le consta lo que pasó después o cómo cobraban los representantes de zona. Que las estaciones de servicio tienen una relación contractual con la empresa para la compra y comercialización de sus productos. Los tanques y surtidores son de la empresa y

se entregan a los concesionarios en comodato, y los concesionarios mantienen la calidad de clientes con Esso mientras cumplan sus obligaciones y las normas de la empresa y por ello considera que las estaciones de servicio son unos clientes especiales. Sin embargo, existen algunas estaciones de servicio que no le interesaban las ventas de combustibles, sino los demás elementos como lubricantes, cubiertas, accesorios, porque en éstos ganaban más que con el combustible. Con los demás clientes, como empresas constructoras y otros, no había concesión, aunque reconoce que los más importantes eran las bocas de expendio. Interrogado por el Tribunal, informa que a su criterio tenía más la característica de un viajante, pues tenía atribuciones, como ciertos límites y cierta elasticidad en cuanto el vencimiento de las facturas vencidas, es decir ampliar plazos de pagos, concertaba ventas con notas de pedidos, y estima de su tiempo de trabajo, entre viajes, cobranzas y ventas, se insumía el 80 %, y el resto se destinaba a trabajo administrativo en la empresa. Que en su zona, era exclusivo, y que cualquiera que se comunicara con la empresa y quería resolver problemas en la empresa, se lo trasladaba al dicente. Que no sabe si figuraba en el libro de viajante, ni si existía ese libro en la empresa. Que le pagaron indemnización por clientela cuando se retiró. Norberto E. Debarre, también comerciante gastronómico, dice haber trabajado para la demandada desde julio de 1970 hasta 1979 ó 1980, en que renunció. Ingresó en la oficina de ventas, para pasar por distintos sectores, fue representante de zona, en la ciudad de Santa Fe. Que promovió juicio a la accionada, en donde se hizo un arreglo y percibió todo. No lo conocía al actor,

pero sabe que hacía las mismas tareas, que el testigo, aunque no lo vio trabajar. Vendían todo lo que la empresa tenía para su venta, combustibles, lubricantes y accesorios, y entre éstos cubiertas, baterías, asfalto, insecticidas, agroquímicos, etc., coincidiendo con el anterior respecto a la forma en que se realizaba la tarea. Considera o califica a las estaciones de servicio como un mercado cautivo, ya que las bocas de expendio se vinculan a la empresa, por medio de un contrato, que debían cumplir. Es decir, que a su criterio, es diferente al cliente común como una ferretería, distribuidor de productos para el hogar, almacenes, etc., quien compra a quien quiere. Sintéticamente, dice que sus tareas eran la cobranza, visitas periódicas, notas de pedidos y seguimiento del cliente, y que las exigencias fundamentales eran objetivo de ventas y otra la cobranza, y se los calificaba por ello. Existía un formulario, cree individualizado como "77 E", y allí se asentaban las ventas de especialidades y productos negros (asfalto, gas-oil y otro combustibles pesados). Que el combustible se vendía a veces a crédito o el llamado plan cosecha, y después debía cobrar. Que al recibo de sueldos se le adjuntaban la liquidación de combustibles, lubricantes y especialidades y las de cobranzas, pero eran ínfimas, la mayor parte eran el sueldo, y las comisiones eran irrelevantes. Se le pagó indemnización por clientela. Interrogado por la parte demandada, dice conocer a Llabot y ser amigo de éste. Que no sabe cuándo ingresó Restivo, aunque está seguro que el actor ingresó después que el testigo, y que tampoco sabe si Restivo ingresó en Santiago del Estero. Que lo que dijo es de cuando él estaba en la empresa. Que Esso hacía una promoción en la época de cosechas en las



estaciones de servicio ubicadas fuera del radio urbano. Que en los llamados servicio el combustible se paga al contado, llega el camión y se le paga al camionero con cheque, y la compra en esos casos es directa. Que existen otros clientes, como empresas de ómnibus, que compran mucho combustible, y en esos casos, se les da crédito o dándole un plazo de pago, y con ello se aumentaba las ventas de combustible. Que en el porcentaje de las ventas, el combustible es preponderante, es el más importante. Que los accesorios, en la época que el testigo trabajaba, representaban un porcentaje menor, pero la venta de ellos era únicamente por medio del representante de zona. Coincide con el anterior que las estaciones de servicios se encuentran vinculadas a la empresa, por medio de un contrato que deben cumplir, y que la empresa les provee en comodato los tanques de combustibles y los surtidores, pero aclara que existían algunos otros clientes que no tenían esas vinculaciones, como empresas constructoras, empresas de ómnibus, etc. que no eran concesionarios, sino clientes. Dice que el representante de zona tenía algunas atribuciones, como ampliar los plazos de pago, entrega de mercaderías con facturas vencidas y que a su criterio el trabajo se asemejaba más a un viajante que a un gerente, pues recorría la zona asignada, concertaba ventas con notas de pedido, y porque esa tarea le insumía la mayor parte del tiempo de trabajo, estimativa igual que el anterior en un ochenta por ciento, y el resto a trabajo administrativo que realizaban en la empresa. Tampoco se sabe si figuraba en el libro de viajeros y reconoce que también le pagaron la indemnización por clientela, cuando se retiró. Oscar F. Floreta, ingeniero civil, conoce a las partes

porque ingresó a trabajar a la empresa en 1972, en la sección ingeniería, y actualmente es coordinador de seguridad, por lo que es personal jerárquico, aunque no tiene atribuciones para suspender o despedir personal. Conoció al actor cuando vino a Córdoba en 1983 ó 1984, como Supervisor de Area para Córdoba y la Zona Norte. Que en ese entonces supervisaba a 6 representantes de zona, y en que el actor estaba en Santiago del Estero, y siguió cuando el dicente se fue. Dice que el representante de zona cumple las disposiciones, instrucciones de la empresa, etc. y que es política de la Compañía llevar actualizada la carpeta de créditos. Que la venta de combustibles es al contado, y que la estación de servicios pide directamente el combustible que necesita y por medio del transportista se hace el flete, y por medio de éste se paga con cheque. Que éste es el grueso del negocio, y a su criterio representa el 90 % de la compañía. Que en lo demás, interviene el representante de zona, y que en el caso de los lubricantes, lo puede hacer la estación de servicios por medio del representante de zona o directamente. Que el representante de zona, debe controlar la seguridad de la estación de servicios, su funcionamiento, hacer cumplir las instrucciones que les imparta la empresa, y controlar los créditos. Que Dellepiane fue representante de zona que renunció hace mucho, pero no puede precisar la fecha. Interrogado por la parte actora, dice que algunas cosas vendían los representantes de zona, como por ejemplo productos, neumáticos, artículos para el hogar, insecticidas, y además vendían combustibles a algunos clientes especiales, como del agro, e intervenían cuando se implementaban algunos planes de promoción. Para todo ello había formularios

adecuados. La cobranza se hacía directamente o por medio del representante de zona. Con estas pruebas y las constancias obrantes a fs. 124/125, referidas al reconocimiento de firmas y autenticidad de la documental por parte de la accionada; la de fs. 125, tendiente a la exhibición por parte de la demandada del libro especial previsto en la ley 14.546 con el certificado del actuario de que la audiencia de reconocimiento de firmas por parte del actor no se realizó por su incomparecencia injustificada del mismo, por lo que haciendo aplicación de los apercibimientos de los arts. 237, 239 y concs. del Cód. de Proced. Civil, deben ser tenidos por auténticos los obrantes en fotocopias a fs. 43/100 de autos y con los informes de fs. 142/229 y fs. 272/275, deben ser resueltas las cuestiones que plantean las partes en estas actuaciones. En la audiencia de la vista de la causa la parte actora solicitó la incorporación de expediente que exhibió en esa oportunidad, y que fueran oportunamente ofrecidos como prueba en la oportunidad procesal respectiva, oponiéndose el apoderado de la demandada la que da sus razones al momento de alegar. Consideramos que la cuestión no es fundamental ya que se trata de antecedentes jurisprudenciales cuyos expedientes han sido ofrecidos como pruebas documentales y que a los fines de la remisión por parte de los tribunales donde se encontraban radicados fueron librados por el Juez de Conciliación y debidamente tramitados, es decir que han sido incorporados en tiempo y forma, y especialmente se encontraban incorporados antes de la elevación de la causa a la Cámara de Trabajo, y el hecho de que los mismos se encontraran en poder del apoderado de la actora al momento de la audiencia de la vista de la

causa, no cambia la incorporación de dichos expedientes en tiempo y forma, de allí que deban incorporarse al debate. La primera cuestión de fondo a resolver es si el actor era viajante de comercio, como se califica en su demanda o representante de zona, como lo encuadra la empleadora. A nuestro criterio, nos encontramos en esas situaciones que resulta difícil deslindar entre una y otra posición, ya que cuesta distinguir o marcar las diferencias por las características tan especiales de la vinculación laboral. No existen dudas que la demandada explota, por medio de concesionarios, estaciones de servicios o bocas de expendio de combustibles, de acuerdo a normas y disposiciones expresas del Estado que regulan esa actividad, es decir que la comercialización, y funcionamiento, instalación, autorización, apertura, cierre, traslado, transferencia y funcionamiento de las bocas de expendio de combustibles se encuentran regladas por leyes, decretos y resoluciones, estas últimas de la Secretaría de Estado de Energía de la Nación. Ha quedado acreditado que dentro de la zona en que desarrollaba su actividad el actor, no existían estaciones de servicios y/o bocas de expendio de propiedad de Esso SAPA, siendo las allí ubicadas de propiedad de terceros, autorizadas por la demandada según las normas de la Secretaría de Energía, así como que los concesionarios adquirirían el combustible directamente a la planta despachadora por el pedido de despachos a granel, y ello ratificado por los dichos de los testigos que expusieron en la audiencia de vista de la causa, e incluso aceptado por el propio actor al absolver posiciones. También se acreditó que el porcentaje mayor de ventas correspondía a los combustibles y que la función principal del representante de zona era la

"atención de los negocios de la zona (servicentros, garages, distribuidores, revendedores, etc.) procurando que éstos cumplan un eficiente servicio de venta y promoción de los productos que comercializa la compañía con exclusividad", siendo los "deberes y responsabilidades básicas: visitar periódicamente los negocios verificando: su stock, buenas condiciones de presentación del negocio e instalaciones, que se promueva la venta de acuerdo con las normas de la compañía. Revisar estado de cuentas de los negocios a fin de poder asesorar al operador sobre el manejo de las mismas. Constatar la existencia de productos que sean de la marca de la compañía o de aquellos que ésta autorizó su venta". Por todas estas características y otras de menor importancia, que no enumeramos por razones de brevedad, el actor debería ser encuadrado como representante de zona. Pero se acreditó en autos también, que el representante de zona realizaba ventas, tales como lubricantes, combustibles llamados pesados, asfalto, neumáticos marca Good Year, baterías marca Champion, repuestos y accesorios para automotores, tales como correas, tapas de tanques de nafta, además de artículos de limpieza, insecticidas, productos para el agro, y que algunos de estos artículos se vendían a empresas constructoras, que no eran concesionarios de la demandada, y que además en las épocas de cosecha, se realizaban planes especiales de ventas de combustibles, es decir que hacían ventas, concertaban negocios para el empleador. Destaquemos aquí, que ese hecho de la venta, quedaría también acreditado, además de los dichos de los testigos y constancias obrantes en autos, por el hecho de que si bien la demandada habla de la categoría de "representante de zona", en los

recibos de haberes aportados al juicio, consta como "puesto: representante de ventas" y que las tareas realizadas fueron "representante de ventas". Acotemos que a mi criterio, no se ha podido determinar en autos, cuál de las funciones tenía mayor preeminencia, importancia o insumía mayor tiempo al actor. Esto unido a que el actor tenía asignada una zona geográfica perfectamente delimitada, que para cumplir su función debía viajar, nos llevaría a la calificación de viajante de comercio. Así las cosas, resulta decisiva la conducta de la demandada de abonar al momento de la rescisión del contrato de trabajo la indemnización por clientela, tal como lo tiene establecido el art. 14 de la ley 14.546, y ello a mi criterio es un expreso reconocimiento de la calidad de viajante de comercio, porque no sólo se paga la indemnización por clientela, sino porque paga exactamente el porcentaje previsto en la norma: 25 % y así lo hace constar en el recibo de fs. 97. Recordemos aquí que el Tribunal Superior de Justicia (sentencia N° 83 del 3/8/1977 ha calificado como viajante de comercio a "quien con habitualidad y permanencia, trabaja personalmente, en la relación de dependencia, representando a uno o más comerciantes o industriales a efectos de concertar negocios relativos al comercio o industria de sus representados, fuera del establecimiento del principal, sin cargar con el riesgo de las operaciones, sin adquirir para sí mismo la masa de clientes y mediante una remuneración", aclarando el Alto Tribunal que la caracterización de la figura del viajante, cumplido algunos de los requisitos del art. 2° de la ley 14.546, compete a los Jueces (Ver Martínez c. Marimón - sentencia del 20/7/1978). En base a todo ello, consideramos que el actor debe ser calificado como viajante de

comercio, dentro de la normativa de la ley 14.546. De esta forma y habiéndose reconocido que el actor ingresó con fecha 19 de septiembre de 1979, ejecutando tareas administrativas y que en noviembre de 1980 pasó a cumplir tareas de viajante de comercio hasta el 20 de septiembre de 1985 en que se rescinde la relación de trabajo por decisión de la empleadora, sin invocación de causa, todos extremos que debemos tener por ciertos, no sólo por las pruebas aportadas, sino también porque en todo ello, salvo la calificación de viajante de comercio, coinciden las partes. Debemos ocuparnos ahora de lo que fundamentalmente plantea la demanda, es decir la petición de "la conversión aritmética del sueldo fijo a comisión a porcentaje"; y nos hemos preocupado de repasar la abundante jurisprudencia y doctrina existente sobre la misma, la que no mencionaremos dado que ambas partes para fundamentar sus posiciones ya la han transcripto, tanto en el escrito inicial como en la contestación, así como en los alegatos. La interpretación, en uno u otro sentido, podríamos decir que prácticamente nace con el dictado de la ley 14.546 (Boletín Oficial del 27/10/1958), hasta llegar a los Acuerdos Plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Simula c. Esso - Plenario 112 del 27/9/67 y Armanda c. Esso - Plenario N° 191 del 30/5/1973), y los numerosos fallos dictados como consecuencia de ello en los Tribunales de esta Ciudad. Compartimos, en principio, el criterio sustentado en dichos plenarios y en los fallos dictados como su consecuencia, es decir que debe hacerse la conversión de la remuneración del trabajador comprendido en la ley 14.546 en comisión, si aquélla no estaba constituida en todo o en parte por este

tipo de retribución, pero también desde un principio se viene simultáneamente desarrollando una doctrina referida al momento en que debe ser realizada esa petición o reclamo. Así en "Maccio c. Parke Davis" (sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - fallo del 26 de junio de 1969 - voto del doctor Fleitas), se confirma el fallo de primera instancia que decide el rechazo de la demanda de diferencias resultantes de la conversión porcentual del sueldo fijo devengado por el demandante, "en el tácito consentimiento del sistema retributivo acordado y que aquél dejara subsistir hasta disuelta la relación laboral..." y se sostiene allí "por lo demás, el fallo en recurso se sustenta en la extemporaneidad de dicho reclamo, propuesto después de disuelta la vinculación y saldadas las cuentas que de ese hecho pudieran derivar, cuando si bien son acertadas las argumentaciones de la apelante que versan sobre las leyes 16.577 y 14.546, la cuestión se centra en realidad sobre la posibilidad de que los efectos de conversiones como la perseguida pueda proyectarse al pasado, asunto ajeno al pronunciamiento de la Cámara en los autos 'Simula c. Esso' y a cuyo respecto la sala no ha tenido oportunidad de decidir expresamente, aunque ha dado algunos lineamientos sobre el particular". Nos remitimos a los demás argumentos realizados en ese fallo y en la nota de Juan C. Fernández Madrid, en el sentido de que el viajante tendrá derecho para el futuro se le asigne un porcentaje de comisión, pero no a beneficiarse indebidamente por el procedimiento de fijar el porcentaje de comisión según las remuneraciones devengadas en un período muy anterior, pues ese sistema podría originar un efectivo desequilibrio en las relaciones que las partes han convenido



voluntariamente. En el mismo sentido se pronunció Deveali al comentar el fallo "Armada c. Esso" (T. S. S. - año I, N° 4, p. 94; T. S. S. - año I, noviembre de 1973, p. 42), nos dice que "Trátase pues de dos problemas igualmente delicados respecto de los cuales no pueden adoptarse, soluciones de alcance general y que deben decidirse de acuerdo a las modalidades de cada caso concreto, ponderando la buena fe que rige normalmente en las relaciones laborales, y de la cual parecen prescindir algunas normas de la ley 14.546 que se prestan, por consiguiente, a soluciones contrarias a ellas". Considero que allí está la cuestión a resolver, es decir teniendo en cuenta el caso particular de cada una de las situaciones que se exponen, tomando las diferencias o similitudes y analizando la conducta de las partes. Partimos que el actor suscribe de conformidad y acepta las condiciones en que le propone la demandada respecto a las remuneraciones, con fecha 28 de noviembre de 1980, es decir después de muchos años de discutida, analizada y resuelta la forma de retribución del viajante de comercio; que según la confesional del accionante "mientras se desempeñó como representante de zona de Esso SAPA, nunca formuló reclamo alguno para que se le pagaran diferencias de sueldos y/o comisiones pactadas" (posición novena del pliego); que durante la relación laboral recibió de conformidad todas las remuneraciones que se le abonaron. Incluso montos elevadísimos por "decisión de la Compañía", que figuran en todos los recibos de haberes; que rescindida la relación laboral, percibe con fecha 20 de setiembre de 1985, todas las remuneraciones, incluso la indemnización por antigüedad, indemnización por clientela, preaviso, integración del mes de despido,

sin formular observación alguna, que con igual fecha acepta "como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo" una importante suma de dinero, superior a la indemnización por antigüedad de seis años, "en concepto de beneficio voluntario", todo según documentación indubitable, y recién después de percibido todo, con fecha 6 de diciembre de 1985, promueve esta demanda. Con todos estos antecedentes no podemos decir que el trabajador ajustó su conducta a la buena fe que le impone el art. 63 de la ley 20.744 (t. o.), obligación que debe existir "tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo", además que la ley impone la obligación, activa y pasiva, no sólo a lo que resulte expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencias del mismo, resultan de la ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad (art. 62, ley 20.744). Se ha dicho que la buena fe adquiere especial preponderancia en el contrato de trabajo, por la naturaleza de la vinculación que éstos generan, eminentemente personal e influida por factores éticos y morales subsumidos en los deberes de colaboración y previsión que asumen dependientes y empleadores, respectivamente, imponiéndoles por igual claridad y definición de manera que ninguna duda pueda caber sobre las posiciones que adopten y sus pretensiones. Cuando más conocimientos, cuando más educación, cuando más cultura, cuando más importantes sean los servicios, cuando más conocimientos tenga el trabajador, más debe ajustar su conducta a la buena fe y a la moral que deben predominar en las relaciones humanas y en los contratos de trabajo; no es lo

mismo, un trabajador manual, un obrero, un jornalero, que una persona que exhibe una educación, relación, conocimientos muy superiores, incluso una mayor ubicación y consideración en la sociedad donde participa. El actor acepta durante cinco años las remuneraciones que se le abonan, incluso el beneficio voluntario que le paga en ese momento su ya ex-empleador, nada dice, ni nada observa, ni reclama, para luego, transcurrido dos meses promover esta demanda. En ella, además no probó cuáles deberían haber sido las remuneraciones que le hubiera correspondido, ni cuáles hubiera sido las justas, ni acredita por qué aceptó aquel sueldo y comisiones, y por qué no las cuestionó. Acepta también que la empresa le adquiriera un vehículo, que le abone los gastos de éste. Por otra parte, y en este caso particular, es necesario destacar que según toda la prueba traída al juicio, el actor percibió comisiones por ventas y por cobranza, y que nos encontramos en una situación muy especial, ya que si bien el actor fue viajante de comercio, la clientela de la accionada, es una clientela "cautiva", para usar el término de la contestación de la demanda, ya que según el informe de fs. 171/228, las estaciones de servicio o bocas de expendio en la zona que trabajó el actor, eran todas de terceros, debían llevar los colores y el emblema de Esso, debían obligatoriamente adquirir y comerciar exclusivamente los productos Esso, y que la mayor parte de las ventas eran las de combustibles, que se realizaban sin intervención del actor, y que las cobranzas de los combustibles se hacían por intermedio de los transportistas, es decir que tampoco participaba en la mayor parte de ella el accionante, todo lo que viene a justificar el porcentaje de comisión convenido

voluntariamente y libremente entre las partes. Tampoco probó el actor cuál era la comisión que se le abonaba al viajante que lo precedió en la zona. Considero que no ha existido por parte de la demandada, dada las condiciones y características expuestas y en especial los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que el actor debió conocer, ya que en la nota de fecha 28 de noviembre de 1980, se hace referencia expresa a la convención colectiva de trabajo N° 65/75 de la Federación Argentina Sindical de Petroleros, vigente al momento de vigencia del contrato de trabajo que vinculó a las partes, abuso del derecho o violación de la norma del art. 1071 del Cód. Civil (concuerda con el art. 68, ley 20.744) porque se ha tratado del ejercicio regular de un derecho, porque abonó una parte en concepto de sueldo y una parte en concepto de comisión, es decir que la remuneración del actor se ajustó a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 14.546. Nos remitimos por razones de brevedad a lo expuesto por Borda (La reforma de 1968 del Código Civil, ps. 84 y sigs.), cuando dice que "El juez debe considerar: 1) si ha habido intención de dañar; 2) si falta interés en el ejercicio del derecho; 3) si se ha elegido entre varias maneras de ejercer el derecho, aquella que es más dañosa para el deudor; 4) si se ha actuado de manera no razonable, repugnando a la lealtad y a la confianza recíproca; 5) si el perjuicio es anormal o excesivo. Respecto a este último punto, es necesario aclarar que no basta, para configurar el abuso, que haya perjuicio para la otra parte de una relación jurídica o para un tercero. Más aún, el resultado normal del ejercicio de un derecho es que haya algún perjudicado, por lo menos en alguna medida". Con estas pautas, y en base a los hechos, llegaríamos a la conclusión que

si existe abuso del derecho, estaría en la conducta del actor, quien realmente persigue con este juicio un enriquecimiento sin causa. En base a todo lo expuesto, me pronuncio en forma negativa a esta primera parte de la cuestión planteada, es decir por el rechazo de la demanda. En virtud de las características del juicio, de la jurisprudencia existente, me decido porque las costas sean soportadas en el orden causado. Hacemos presente que hemos hecho aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas en la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco a tratar todas las cuestiones expuestas, ni a analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos: 276:132; 280:320; 301:602), entre otros.

El doctor Marcattini dijo:

Que haciendo suyos los dichos del vocal de Cámara preopinante, vota en idéntico sentido. La categoría de viajante dada por el colega en ilustrada consideración no contradice, en esencia, la manera de tener en cuenta otros matices que colorean el derecho que consagran. En este caso singular lo ha puesto en evidencia en forma acabada y sin duda alguna el colega preopinante. De allí que tanto la conducta asumida por el actor, el pago que percibió de sus remuneraciones y su aceptación

sin objeciones hasta el final del trato que tuvo con la empleadora graviten sustantivamente en sus pretensiones que devienen en inadmisibles.

El doctor Allende dijo:

Que haciendo suyos los dichos del vocal de Cámara preopinante, doctor Podestá, vota en igual sentido.

Atento el resultado de la votación que antecede, previa deliberación y acuerdo, por unanimidad, el tribunal resuelve: rechazar la demanda promovida por Sergio G. Restivo en contra de la razón social "Esso SAPA" (ley 14.546 - arts. 62, 63, 68 y conchs. ley 20.744). Las costas en el orden causado.-

Pascual O. Podestá.- Rómulo L. Marcattini.- Rafael Allende.- Ante mí: Mario R. Lescano.